

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3467/2565

พนักงานอัยการจังหวัด

โจทก์

เด็กหญิง อ. โดยนาง ว. ผู้แทนเฉพาะคดี

โจทก์ร่วม

นาย ง.

จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่),
มาตรา 279 วรรคสาม (เดิม)

ตาม ป.อ. มาตรา 3 ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับ
กฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้
กระทำความผิดไม่ว่าในทางใด การที่จำเลยใช้นี้สอดคล้องเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้
เสียหาย เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามมาตรา 277
วรรคสาม (เดิม) ที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่ภายหลังจำเลยกระทำความผิดและ
ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27)
พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การกระทำความผิดดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานกระทำชำเราอีกต่อไป
แต่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำ
อวัยวะเพศตามมาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ซึ่งความผิดฐานกระทำอนาจาร
ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 279 (ที่แก้ไขใหม่) จึงชอบด้วยมาตรา 3
และเป็นบทกฎหมายที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ซึ่งศาลย่อมลงโทษจำเลยฐานกระทำ
อนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำอวัยวะเพศตามมาตรา 279
วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ที่เป็นคุณแก่จำเลยมากกว่านั้น มิใช่ตามมาตรา 279 วรรค

แรก (เดิม) แต่ความผิดตามมาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษเท่ากับ
ระวางโทษตามมาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำ
ความผิด ระวางโทษตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่จึงไม่เป็นคุณแก่จำเลย ศาลต้อง
กำหนดโทษจำเลยตามมาตรา 277 วรรคสาม (เดิม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 279

ระหว่างพิจารณา เด็กหญิง อ. ผู้เสียหาย โดยนาง ว. ยายของผู้เสียหาย ซึ่งเป็น
ผู้แทนเฉพาะคดียื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
279 วรรคสองและวรรคห้า ประกอบมาตรา 80 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้นิ้วมือล่วง
ล้ำอวัยวะเพศ จำคุก 12 ปี ฐานพยายามกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี
จำคุก 2 ปี 8 เดือน ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี จำคุก 4 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้
กระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานกระทำอนาจารแก่เด็ก
อายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้นิ้วมือล่วงล้ำอวัยวะเพศ คงจำคุก 6 ปี ฐานพยายาม
กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ฐานกระทำ
อนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี คงจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 9 ปี 4 เดือน

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม), 279 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) ประกอบมาตรา 80 ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้นิ้วมือล้วงล้ำอวัยวะเพศจำคุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 5 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมในประการแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปรับบทลงโทษจำเลยในความผิดตามฟ้องข้อ 1.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 บัญญัติว่า ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใด... การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ 1.1 เมื่อประมาณปลายเดือนเมษายน 2562 โดยจำเลยใช้นิ้วมือสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายนั้น เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่ภายหลังจำเลยกระทำความผิดและก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บัญญัติให้การกระทำความผิดดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานกระทำชำเราอีกต่อไป แต่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล้วงล้ำอวัยวะเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ซึ่ง

ความผิดฐานกระทำอนาจารตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 (ที่แก้ไขใหม่) จึงชอบด้วยมาตรา 3 และเป็นบทกฎหมายที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ซึ่งศาลย่อมลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำอวัยวะเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ที่เป็นคุณแก่จำเลยมากกว่านั้น มิใช่ตามมาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย ฎีกาของโจทก์รวมในข้อนี้ ฟังขึ้น แต่ความผิดตามมาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต เท่ากับระวางโทษตามมาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด ในส่วนระวางโทษตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่จึงไม่เป็นคุณแก่จำเลย ศาลต้องกำหนดโทษจำเลยตามมาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) และเมื่อโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดให้จำคุก 4 ปี ก่อนลดโทษนั้น ต่ำกว่าโทษขั้นต่ำตามระวางโทษดังกล่าว แต่โจทก์รวมฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้นด้วย ศาลฎีกาจึงแก้ไขกำหนดโทษให้ถูกต้องได้

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์รวมในประการต่อไปมีว่า มีเหตุสมควรลงโทษสถานหนักโดยไม่ลดโทษให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ 31 ปีเศษ ควรรู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว แต่จำเลยกลับอาศัยความเป็นบิดาเลี้ยงที่สามารถครอบงำและใกล้ชิดผู้เสียหายกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 11 ปีเศษ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ชีวิตและอนาคตของผู้เสียหายทั้งเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน พฤติการณ์ในการกระทำความผิดของจำเลยเป็นเรื่องที่ร้ายแรง และเพื่อไม่ให้เป็นการเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรลงโทษจำเลยให้หนักขึ้นกว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนด ส่วนที่โจทก์รวมฎีกาว่าไม่ควรลดโทษให้แก่จำเลยก็หนึ่ง

เนื่องจากจำเลยรับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานนั้น เห็นว่า คดีนี้จำเลยขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธเป็นให้การรับสารภาพตามฟ้อง โดยโจทก์และโจทก์ร่วมยังมิได้สืบพยาน จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการรับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐาน คำรับสารภาพของจำเลยเป็นการให้ความรู้แก่ศาล อีกทั้งจำเลยยังได้พยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นโดยวางเงิน 30,000 บาท ต่อศาลชั้นต้น เพื่อขอใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย อันเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ที่ศาลล่างทั้งสองลดโทษให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของโจทก์ร่วมในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม), 279 วรรคสองและวรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ประกอบมาตรา 80 ความผิดตามฟ้องข้อ 1.1 ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำอวัยวะเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ให้กำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) จำคุก 7 ปี ความผิดตามฟ้องข้อ 1.2 ฐานพยายามกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) ประกอบมาตรา 80 จำคุก 4 ปี และความผิดตามฟ้องข้อ 1.3 ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) จำคุก 6 ปี รวมจำคุก 17 ปี เมื่อลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 8 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ธีระ เบญจรัศมีโรจน์-วยุรี วัฒนวรลักษณ์-สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายวรวิทย์ ฤทธิทิศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ